

1501694-57.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... e nunca soube que tivesse envolvimento com o tráfico de drogas. Sabe apenas que é caminhoneiro e sempre trabalhou (v. mídia).

A testemunha Vitor, arrolada pela Defesa de Hely, disse que o acusado Hely é companheiro de serviço, visto que ambos são caminhoneiros, desconhecendo se tem envolvimento com tráfico (v. mídia).

O réu Hely, quando interrogado na fase policial, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501694-57.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501694-57.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2197420/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 19171537 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 1900/21/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2197420 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 1900/21/907 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELY EVERTON DEVATZ e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

HELY EVERTON DEVATZ e TALES DE JESUS MUNIZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 21 de julho de 2021, por volta das 20h30min, na Avenida Antônio Vanzela, esquina com a

Avenida Aléssio Mazer, Jardim Santa Marta, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, os acusados, agindo em concurso e com identidade de desígnios, transportavam e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico 972,93g (novecentos e setenta e dois gramas e noventa e três decigramas), de Cocaína, na forma de Crack, acondicionada em 01 (um) invólucro plástico, e 14 (catorze) porções da substância popularmente conhecido como Maconha, compactadas sob a forma de tijolos, pesando 8,700kg (oito quilos e setecentos gramas).

Segundo a denúncia, Hely foi contratado por Tales para buscar entorpecentes nesta cidade e depois transportá-los para a cidade de Bebedouro/SP, para posterior distribuição e comercialização. Para tanto, os acusados, ocupando o veículo Fiat/Pálio EX, placa DBG-6189/Colina-SP, de cor branca, saíram da cidade de Bebedouro e rumaram até esta urbe. Aqui chegando, encontraram-se com outro traficante, que lhes entregaram aproximadamente um quilo de Cocaína na forma de Crack e quase nove quilos de Maconha. Ocorre que, quando retornavam para a cidade de Bebedouro, policiais militares avistaram o referido veículo trafegando pelo local acima mencionado, momento em que Hely, condutor do automóvel, ao avistar a viatura, freou-o bruscamente e Tales, que ocupava o banco do passageiro ao lado do condutor, abriu as portas e evadiu-se do local, fato que gerou suspeita, culminando com a abordagem de Hely.

Questionado, Hely admitiu ter sido contratado por Tales para buscar a droga em Sertãozinho/SP e levá-la até Bebedouro/SP e que receberia pelos serviços prestados a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Então, os policiais realizaram busca veicular e encontraram no banco traseiro 13 (treze) tijolos e meio de maconha e 08 (oito) porções de Cocaína na forma de Crack. Diante de tais fatos, Hely foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para as medidas legais cabíveis. Realizadas as diligências pela Polícia Civil, Tales foi identificado como sendo o indivíduo que fugiu do veículo antes da abordagem e, realizado o reconhecimento fotográfico, o policial militar Ulisses o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo o outro autor do delito em questão (fls. 122).

A denúncia foi recebida em 27 de agosto de 2021 (fls. 137/138), os réus foram devidamente citados (fls. 150 e 152) e apresentaram resposta à acusação (fls. 145/147 e 155/160).

Durante a instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Defesa de Hely, sendo os réus interrogados ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 276/284).

A Defesa do réu Tales requereu absolvição do réu por insuficiência probatória, e em caso de condenação, o reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução da pena no patamar máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto (fls. 288/293).

A Defesa do réu Hely requereu a absolvição, por falta de provas e, em caso de condenação, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º da referida Lei de Drogas, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, expedindo-se alvará de soltura, além do direito de recorrer em liberdade (fls. 294/298).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 19/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), pelo auto de constatação preliminar (fls. 24/25), pelas imagens fotográficas (fls. 29/34), pelos laudos químico-toxicológicos (fls. 111/118 e 115/117), conclusivos por se tratar de Cocaína e de Maconha, pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 122), e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também foi devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos.

Os policiais militares Ulisses Silveira da Silva Gonçalves e Antônio Cesar Cardoso

Junior, arrolados como testemunhas de acusação, na fase policial, disseram que, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistaram o veículo em atitude suspeita, sendo que quando da aproximação da viatura policial, o condutor freou bruscamente, momento no qual o passageiro abriu a porta do veículo e saiu correndo, não sendo alcançado pelos policiais. Foram observadas as características físicas do fugitivo, o qual trajava roupas vermelhas (camiseta e bermuda), cor parda e aproximadamente 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) de altura. Abordado o condutor do carro, este afirmou que ganharia R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para transportar os entorpecentes de Sertãozinho/SP à Bebedouro/SP, sendo que o comerciante dos entorpecentes seria o indivíduo que estava no banco de passageiro. Foram apreendidas dentro do veículo (DBG-6189), no banco traseiro, 13 (treze) tijolos e meio de Maconha e 08 (oito) porções de Crack (fls. 05/06). Em Juízo, o policial Ulisses disse que o patrulhamento estava sendo realizado em local conhecido pelo tráfico de drogas, e que o condutor do veículo afirmou que era vizinho de Tales. Acrescentou que foi possível verificar a fisionomia de Tales e que o perseguiu por cerca de 03 quarteirões. Notou que esse rapaz que empreendeu fuga tinha tatuagens da lateral da cabeça. Reconheceu em Juízo ambos os réus, bem como indicou o réu Tales como sendo o indivíduo que fugiu, assim como o indicou dentre as fotos de fls. 122 (v. mídia).

Em Juízo, o policial Antônio reiterou as declarações da fase policial, acrescentando que Hely disse que ele e Tales eram próximos e por esse motivo o "Barão" teria pedido o "favor". O Policial afirmou ainda que Hely confessou, informalmente e no momento de seu interrogatório, que foi para Sertãozinho já sabendo que transportaria as drogas para Tales. Quanto ao réu que fugiu, Antônio afirmou que ele e o colega de farda o perseguiram, mas não obtiveram sucesso na captura (v. mídia).

A testemunha Maria Aparecida, arrolada pela Defesa de Hely, disse ser vizinha da genitora do réu Hely, que não presenciou os fatos e nunca soube que tivesse envolvimento com o tráfico de drogas. Sabe apenas que é caminhoneiro e sempre trabalhou (v. mídia).

A testemunha Vitor, arrolada pela Defesa de Hely, disse que o acusado Hely é companheiro de serviço, visto que ambos são caminhoneiros, desconhecendo se tem envolvimento com tráfico (v. mídia).

O réu Hely, quando interrogado na fase policial, disse que reside na cidade de Bebedouro/SP e trabalha como motorista de caminhão para a Transportadora Detoni. Estando em situação financeira difícil, foi procurado por um indivíduo de nome Tales, o qual mora nas proximidades de sua residência e lhe ofereceu R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para transportar uma quantidade de entorpecentes de Sertãozinho/SP para Bebedouro/SP. Afirmou ter plena consciência do tipo de transporte, pois observou o carregamento de entorpecentes em seu veículo, um Fiat Palio de cor Branca de placas DBG-6189 (fls. 07).

Em Juízo, negou a acusação. Disse ser carreteiro e que foi contratado pelo aplicativo Trans Vale, da empresa onde trabalha. Disse que foi chamado para transportar objetos pessoais por uma pessoa chamada Charles, em Bebedouros. Narrou que foi abordado pelos policiais e nesse momento o passageiro fugiu. Alegou nunca ter se envolvido com drogas e que não conhece o corréu. Negou ter dito aos policiais que o contratante se chamava Tales ou que ele tinha o apelido de "Barão". Não percebeu que estava transportando drogas pois estava tudo em sacolas e mochilas, sendo que não chegou a ver o entorpecente, nem mesmo após a abordagem. Não prestou depoimento na Delegacia de Polícia, só assinou alguns papéis, sem ler, acrescentando que não falou com o delegado e que foi impedido de falar com a família (v. mídia).

O réu Tales, quando interrogado na fase policial, negou a participação no delito em questão. Afirmou que não conhece Hely Everton Devatz e que saiu há pouco tempo da Fundação Casa e não conhece quase ninguém de fora da Fundação. Disse que nunca viu e que nunca conversou com Hely. Cientificado do reconhecimento fotográfico existente nos autos, negou ser o indivíduo que estava no veículo com o acusado Hely. Negou, ainda, que estivesse em Sertãozinho/SP na noite de 21 de julho de 2021. Afirmou que está preso em um processo de tráfico de drogas, mas negou que

seja culpado, alegando que é perseguido por policiais militares. Por fim, disse que ficou internado duas vezes na Fundação Casa, ambas por tráfico de drogas (fls. 104).

Em Juízo, o réu Tales reiterou a negativa. Disse que trabalha como ajudante de pintor e que não está envolvido com o tráfico de drogas. No momento dos fatos, alegou que estava em casa com a esposa (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que os acusados eram realmente os proprietários da droga apreendida e que se destinaria à comercialização.

Os policiais militares Ulisses e Antônio narraram de maneira uníssona, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, que, em patrulhamento, avistaram um veículo em atitude suspeita e, quando a viatura policial se aproximou, o réu Hely freou bruscamente e o indivíduo que estava no banco do passageiro saiu correndo e empreendeu fuga.

Entretanto, os policiais conseguiram visualizar as características físicas do indivíduo, o que permitiu que o policial Ulisses reconhecesse o réu, tanto na fase policial quanto em Juízo.

O réu Hely, por sua vez, foi preso em flagrante delito, e era o responsável por conduzir o veículo onde, em seu banco traseiro, havia 13 (treze) tijolos e meio de maconha, com peso de 8 quilos e 700 gramas, além de cerca de quase 1 kg de crack, material este já atestado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), podendo ser visualizado ainda nas imagens fotográficas (fls. 29/34).

A ilicitude do material encontrado foi também averiguada pelos laudos químico-toxicológicos (fls. 111/118 e 115/117), conclusivos por se tratar de Maconha e Cocaína.

Ademais, importante observar que o réu Hely, na fase policial, confessou a prática delitiva, dizendo que aceitou a oferta de Tales para transportar entorpecentes de Sertãozinho/SP para Bebedouro/SP, por R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), porém em Juízo negou todas as acusações e retificou sua confissão, afirmando desconhecer o corréu Tales.

Tal confissão policial, porém, não pode ser desprezada, notadamente por ser coerente e compatível com as demais provas produzidas nos autos, notadamente o relato dos policiais e o fato de que o corréu Tales só foi identificado pelo fato de Hely ter ainda confirmado seu apelido e informar que seria seu vizinho.

Não bastasse, caberia ao acusado demonstrar que a confissão perante a autoridade policial foi obtida por meio ilícito, porque ser presumível que a autoridade policial age no estrito cumprimento do dever legal.

A negativa de Hely, de que não sabia que transportava droga, também não convence frente à grande quantidade apreendida, bem como considerando que ao menos estava escondida no veículo, mas disposta sobre o banco traseiro, em sacola transparente, de fácil visualização, e ainda por se tratar de grande quantidade da droga maconha (8,700 kg), que ter forte odor característico.

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de policiais para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos: "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-

74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Coeso testemunho dos policiais militares – Validade – Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório – Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas – Tráfico caracterizado – Condenação mantida – PENA – redutor no patamar máximo – necessidade – Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto – Recurso parcialmente provido. (TJSP – Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 – Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves – d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP – Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 – Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira – d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVA ORAL INCRIMINADORA – A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES – O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP – APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 – Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib – d.j. 14.11.2017).

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200).

Assim, considerando a elevada quantidade de droga encontrada, superior ao que normalmente é encontrado com meros usuários, conclui-se que a droga apreendida efetivamente era destinada ao tráfico.

A acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação dos réus como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base dos réus no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu Tales era menor de 21 anos na data dos fatos. O réu Hely ainda é confesso, ainda que somente na fase policial. No entanto, tais circunstâncias não tem o poder de fazer com que a pena seja reduzida abaixo do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, reputo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Tal benesse deve ser concedida apenas aos agentes primários, de bons antecedentes, e que não se dediquem a atividades criminosas e nem integrem organização criminosa.

Porém, no presente caso, foi apreendida grande quantidade de droga, a saber, 972,93g (novecentos e setenta e dois gramas e noventa e três decigramas) de Cocaína, na forma de Crack, além de 14 (catorze) porções da substância popularmente conhecido como Maconha, compactadas sob a forma de tijolos, pesando 8,700kg (oito quilos e setecentos gramas). Além de indicativa de profissionalização nas condutas, a elevada quantidade apreendida representa um perigo maior à saúde pública, por atingir inúmeros usuários, de forma que sua conduta evidentemente implica alto risco à sociedade.

O réu Tales também já foi processado diversas vezes perante a Vara da Infância e Juventude, bem como internado na Fundação Casa (v. Fls. 172/173 e interrogatório judicial), a permitir concluir que continua praticando delitos como meio de vida. A quantidade encontrada ainda indica que os réus possuem forte e duradoura ligação com o narcotráfico, pois caso contrário, não lhes seria confiada tão valiosa mercadoria.

Destaco ainda a natureza de alta potencialidade lesiva da droga crack encontrada com os réus, a qual tem enorme capacidade de causar rápida dependência e efeito devastador à saúde.

Por todos referidos motivos, os réus não podem ser considerados meros traficantes eventuais ou se sustentar que não se dedicam a atividades criminosas.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitivas as penas fixadas.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça

material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, além de a penalidade imposta impedir, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime, bem como conveniente e adequada a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao réu, nos termos do artigo 33, § 3.º, do Código Penal.

Inicialmente observo que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente sã, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

O crime em tela, ademais, é equiparado a hediondo e, tendo em vista o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464, de 28/março/2007, a fixação do regime inicial fechado era mesmo de rigor.

Não bastasse, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em conta ainda as regras previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A propósito, observo que foi apreendido em poder dos acusados grande quantidade de entorpecente, inclusive da droga crack, que é substância muito nociva e que causa rápida dependência química e efeito devastador à própria saúde e à sociedade. E pelos mesmos motivos que justificaram a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, ainda mais considerando que Hely permaneceu preso durante todo o processo, para garantia da ordem pública, nada justificando a soltura após a condenação, e que o Tales ostenta inúmeras condenações enquanto adolescente e é recém egresso da Fundação Casa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus HELY EVERTON DEVATZ e TALES DE JESUS MUNIZ, qualificados nos autos, cada qual à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Declaro a perda, em favor da União, do veículo apreendido (Fiat Palio - placas DBG-6189/Colina), vez que há prova segura de que foi utilizado para a prática do tráfico.

Em face da condenação, os réus arcarão com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso sejam beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu Tales e ofício de recomendação em relação ao réu Hely.

P.R.I.C.

Sertãozinho, 07 de janeiro de 2022.

Angel Tomas Castroviejo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA